

1500507-07.2022.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: João Carlos Germano

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/10/2022

... atribuindo a ele a prática do crime de tráfico de drogas.

A testemunha Luiz Gustavo da Silva Barbosa, ouvida em juízo, relatou que estavam em patrulhamento quando receberam, pelo COPOM, uma ocorrência sobre dois indivíduos armados. Mencionou que existe uma adega na rua, conhecida pelo tráfico de drogas. No local, visualizaram uma motocicleta saindo do estabelecimento, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté

Foro de Taubaté

3ª Vara Criminal

Praça Monsenhor Silva Barros - s/nº, Fórum Criminal

CEP: 12020-070 - Taubaté - SP

Telefone: (12) 2124-9113 - E-mail: taubate3cr@tjsp.jus.br

1500507-07.2022.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500507-07.2022.8.26.0618

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ VINICIUS DE JESUS

Juiz de Direito: João Carlos Germano

Vistos.

Luiz Vinicius de Jesus foi denunciado pelo Ministério Público porque, no dia 16 de abril de 2022, por volta das 22h30min, na Rua Walter Pereira de Faria, próximo ao nº 64, Bairro Jardim Mourisco, nesta cidade e comarca de Taubaté, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, transportava e trazia consigo, para fins de venda a terceiros consumidores, 21 pedras de crack, subproduto da cocaína, com massa líquida de 6,62 gramas, bem como 20 pinos e 12 porções de cocaína, com massa líquida de 18,45 gramas, substâncias causadoras de dependência física e psíquica.

Segundo apurado pela acusação, o réu vinha deliberadamente praticando o comércio de drogas visando a auferir renda fácil e rápido ante a rentabilidade que o tráfico proporciona.

Foi então que, na noite dos fatos, enquanto conduzia uma motocicleta e transportava consigo certa quantidade de drogas, destinadas à venda, ele foi abordado por

policiais em patrulhamento de rotina.

Na ocasião, os policiais receberam informações pelo COPOM sobre uma ocorrência mencionando que havia um indivíduo armado, sendo repassado as suas fisionomias e o local onde ele se encontrava.

Rapidamente, eles se deslocaram até o endereço indicado e avistaram o réu, na companhia de Igor Felipe, sendo que ambos haviam acabado de sair de uma adega.

Diante da informação recebida, os policiais foram ao encalço deles e acionaram o sinal luminoso da viatura dando ordem de parada, a qual foi desobedecida.

Durante a fuga, o réu colidiu a moto contra o meio-fio e caiu ao solo, momento em que tentou fugir e dispensou uma sacola. Seu amigo também tentou empreender fuga, porém, ambos foram abordados.

Efetuada revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado na posse deles. Na sacola dispensada, foram localizadas 21 pedras de crack, 20 pinos e 12 porções de cocaína, prontas para serem vendidas.

Em razão do seu estado flagrancial, o réu foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia.

Busca, assim, a condenação do réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A denúncia foi recebida às fls. 73/76.

Citado pessoalmente (fls. 95), o réu apresentou resposta escrita à acusação às fls. 96/100.

Designou-se audiência, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas e procedeu-se ao interrogatório do réu, colhendo-se alegações finais do Ministério Público e da Defesa.

O Ministério Público postulou a procedência do pedido, alegando que a autoria e a materialidade do delito foram devidamente comprovadas pelas provas existentes nos autos. Ouvidos em juízo, os policiais confirmaram os fatos e todas as circunstâncias, mencionando que o réu desobedeceu ao sinal de parada e dispensou uma sacola de entorpecentes. A testemunha Igor, que estava na companhia do réu, escutou os disparos e negou a posse das drogas. Interrogado, o réu justificou que fugiu em razão dos disparos, negando a posse das substâncias ilícitas. Nesse cenário, afiançou que a palavra dos policiais e a apreensão das drogas corrobora o crime descrito na denúncia. Além disso, afirmou que nada existe de concreto a tornar suspeito o depoimento policial, uma vez que não foram produzidas provas para comprovar o flagrante forjado, bem como o réu não comprovou a propriedade da motocicleta, sendo que não era habilitado e evadiu-se após o sinal de parada. Portanto, requereu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia. Na dosimetria, ausentes circunstâncias especialmente desfavoráveis, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal, destacando a primariedade e a menoridade. Ademais, pediu que seja aplicado o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. no tocante ao regime, defendeu a aplicação do semiaberto, com possibilidade de substituição da pena.

A Defesa, por sua vez, requereu a improcedência do pedido, por insuficiência de provas. Manifestou que nada comprova que o réu tenha dispensado a sacola de entorpecentes. Pelo contrário, ele negou os fatos em todas as fases do processo e esclareceu com riqueza de detalhes o ocorrido, justificando que se evadiu do local por não ser habilitado e por ter escutado disparos de arma de fogo, versão

corroborada pelas testemunhas. Salientou que as imagens da abordagem demonstram que as pessoas próximas se dispersaram ao ouvir os tiros, fato também narrado pela Defesa. Outrossim, enfatizou que nada de ilícito foi apreendido na casa dele, assim como nenhum apetrecho relacionado a traficância, e os policiais não o conheciam anteriormente. Ressaltou, ainda, que nenhuma testemunha presenciou a dispensa da sacola de drogas, somente o policial. No mais, apenas o réu foi detido, e o segundo indivíduo foi liberado na Delegacia. Ademais, destacou que os policiais não estavam devidamente identificados. Por todas essas circunstâncias e com base no princípio do in dubio pro reo, pleiteou a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Em eventual condenação, postulou a fixação da pena-base no mínimo legal, com aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, em patamar máximo, considerando que o réu é primário, menor de idade e não integra organização criminosa. Além disso, solicitou a aplicação de regime aberto. Por fim, pediu que seja concedida a isenção das custas processuais e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Decido.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada, por meio da qual o Ministério Público requereu a condenação do réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Não há questões preliminares a se enfrentar. As condições da ação estão presentes, assim como os pressupostos processuais, o que rende ensejo à apreciação do mérito.

É o caso de acolhimento do pedido condenatório.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1), termo de depoimento (fls. 2/5), termo de interrogatório (fls. 6/7), auto de qualificação, vida pregressa e BIC (fls. 14), boletim de ocorrência (fls. 15/18), auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), laudo pericial (fls. 38 e 202/204) e pelos depoimentos colhidos em juízo.

Com relação à autoria, melhor sorte não assiste o acusado, em razão da robusta prova atribuindo a ele a prática do crime de tráfico de drogas.

A testemunha Luiz Gustavo da Silva Barbosa, ouvida em juízo, relatou que estavam em patrulhamento quando receberam, pelo COPOM, uma ocorrência sobre dois indivíduos armados. Mencionou que existe uma adega na rua, conhecida pelo tráfico de drogas. No local, visualizaram uma motocicleta saindo do estabelecimento, sendo que o motorista era o indivíduo identificado. Por consequência, deram sinal de parada, desobedecido por ele. Narrou que ele foi abordado em outro bairro, após colidir a moto. Na oportunidade, foi atrás do indivíduo que estava na garupa do automóvel e realizou sua abordagem. Nada de ilícito com ele. Em seguida, foi solicitado para levá-lo próximo ao outro, porque o réu teria algo ilícito em sua posse. Seu parceiro informou que ele teria dispensado uma sacola com entorpecentes. Não visualizou nada disso. Questionado, disse que outras viaturas acompanharam a ocorrência, acionadas pelo rádio. Confirmou que estavam devidamente qualificados e com sinal luminoso acionado. Alegou que foram até a residência do réu porque ele estava sem documentação. Na casa, deram ciência da prisão à irmã dele, que solicitou auxílio para encontrar os documentos. Garantiu que, após encontrarem o RG dele, imediatamente saíram do imóvel. Além disso, deixaram os pertences do segundo indivíduo com a esposa dele, que também morava naquela rua. Anotou que conhecia o réu por uma denúncia anterior. Negou que tenham realizados disparos de arma de fogo, justificando que o barulho pode ter sido proveniente do escapamento irregular da motocicleta.

A testemunha José Custódio Vieira, ouvida em juízo, relatou que foram acionados por uma ocorrência de posse de arma de fogo em uma adega. No endereço, uma motocicleta evadiu-se do local após visualizar a viatura, contando com dois indivíduos. Em razão disso, deram sinal de parada, ignorado por eles. No bairro próximo, o motorista colidiu a moto e ambos saíram correndo, em direções opostas. Nesse momento, foi atrás do réu e viu quando ele dispensou a sacola com entorpecentes. Citou que estava a uma distância de 3 metros dele. Afirmou que estavam sozinhos nessa ocasião. Enquanto isso, seu parceiro tentou abordar o segundo indivíduo. Alegou que não o conhecia anteriormente. Informou que outras viaturas estavam chegando no local para auxiliá-los. Posteriormente, foram na residência do réu, mas não ingressou no imóvel, pois ficou cuidando da segurança dos indivíduos detidos. Negou os disparos de arma de fogo.

A testemunha Igor Felipe do Carmo Angrisani Gomes, ouvida em juízo, informou que estava na companhia do réu no momento dos fatos. Afirmou que a motocicleta era de um amigo do réu. Estavam indo em uma adega. Não entraram no estabelecimento porque teriam que pagar R\$15,00. Questionado, disse que não pararam porque não visualizaram o sinal de parada. Em uma rua próxima, ouviram um sinal de disparo de arma de fogo e começaram a correr. Após a colisão, continuaram correndo em razão dos disparos. Mencionou que ouviu 4 tiros. Negou que os entorpecentes estivessem na posse do réu. Indagado, negou que tivessem outras viaturas no local inicial. Narrou que foi abordado por policiais da ROCAM. Na Delegacia, percebeu que os policiais estavam sem identificação.

A testemunha Kaique da Silva Claro, ouvida em juízo, informou que é vizinho do réu. Afirmou que estava no local da ocorrência e visualizou os fatos, na companhia de outras 4 pessoas. Narrou que viu o momento em que os dois subiram a praça e pularam o canteiro, tentando entrar na avenida. No entanto, as viaturas já estavam no local, fazendo com que eles retornassem. Nesse momento, ouviu dois disparos. Todos correram. Em seguida, ouviu o terceiro disparo. Quando retornou, avistou o réu sendo abordado e colocado dentro da viatura. Logo após, os policiais foram atrás do segundo indivíduo. Negou que o réu tenha dispensado uma sacola. Confirmou que os policiais foram os autores dos disparos. Não tem conhecimento sobre o proprietário da moto.

A testemunha Gelissa Bianca de Jesus, ouvida em juízo, informou que é irmã do réu. Relatou que os policiais foram até sua residência e imediatamente entraram no imóvel. No momento, eles colocaram todos na área externa e revistaram todos os cômodos, mas não encontraram nada ilícito. Na oportunidade, perguntou o motivo da prisão e o policial disse que a ocorrência era da ROCAM, sendo que não tinham encontrado nada. Ele não quis fornecer seu nome e não estava com identificação. Disse que seu irmão trabalha como vendedor de lanches.

O réu Luiz Vinicius de Jesus, interrogado em juízo, asseverou que tem conhecimento da acusação e negou que seja verdadeira. Narrou que estava trabalhando no carrinho de lanches quando seu amigo apareceu, convidando-o para comprar bebidas. Na adega, precisavam pagar R\$15,00 para entrar, motivo pelo qual decidiram ir embora. Assim que saíam, deparou-se com a viatura, que não deu sinal de parada, e continuou andando normalmente. Em uma rua próxima, escutou um barulho de disparo de arma de fogo e correu com medo. No outro bairro, virou-se e viu que era a viatura. Por achar que eles estavam tentando matá-lo, continuou fugindo, mas acabaram caindo. Continuaram fugindo a pé. Perguntado, discorreu que não parou porque ficou com medo. Citou que não tinha habilitação. Na ocasião, foi abordado pela ROCAM e conduzido à Delegacia por ter desobedecido a ordem de parada. Disse que outra viatura fez a abordagem de seu amigo. Na Delegacia, teve conhecimento sobre os entorpecentes. Além disso, eles afirmaram que essa acusação serviria para justificar os disparos. Negou ser usuário de drogas. Explicou que a motocicleta era sua, comprada há alguns dias. Não tem documentação da compra. Não conhecia os policiais anteriormente. Disse ter 20 anos, solteiro e não tem filhos; mora com a

irmã; trabalha como vendedor de lanches, com renda média de R\$70,00 por dia; não tem outros processos.

Bem provadas a autoria e a materialidade.

Dispõe o artigo 33, caput, da Lei de Drogas:

"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:"

Dos elementos de informação colhidos no inquérito policial que se somam às provas produzidas sob o contraditório judicial, verifica-se que a conduta do réu se enquadra no verbo trazer consigo drogas, previsto no núcleo do tipo, assim, configurada a traficância.

Com efeito, os policiais ouvidos afirmaram que depois de receberem uma denúncia, próximo de uma adega, avistaram o réu e seu carona em uma moto e deram sinais de parada, sendo que eles empreenderam fuga. Foram atrás deles e, depois de uma perseguição, o réu bateu a motocicleta no meio fio e caíram ao chão, sendo que cada um correu para um lado.

Um dos policiais seguiu o réu e verificou que ele, ao correr, dispensou uma sacola que, posteriormente, foi coletada e onde as drogas se encontravam.

Soma-se ao relato dos policiais a apreensão das drogas, corroborando os fatos por ele afirmados.

Dessa forma, estão os fatos devidamente comprovados e demandam a responsabilidade do réu pelo evento.

As alegações defensivas, por sua vez, não convencem.

Anoto que o fato de haver apenas o testemunho dos policiais, não é razão para desconsiderar o teor dos depoimentos, ainda mais sem qualquer outro elemento de prova idôneo em sentido contrário.

Registro que os depoimentos prestados são coesos e harmônicos, inclusive reproduzindo, com fidelidade, o quanto afirmado no depoimento prestado na Delegacia de Polícia, dando conta do ocorrido na data dos fatos.

A propósito da questão, pacífico nos tribunais, inclusive nos superiores, que "O depoimento de policiais é elemento idôneo à formação da convicção do magistrado quando em conformidade com as demais provas dos autos." (STJ AgRg no AREsp 262.655/SP 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.2013 DJU 14.06.2013).

Ressalto que os agentes policiais, no exercício de suas funções, são os primeiros, quando não os únicos, a travarem contato pessoal com a prática delituosa e, nessa condição, a sua interpretação sobre os fatos ocorridos reveste-se de especial importância.

Em virtude da experiência no combate à criminalidade, os policiais têm o discernimento necessário para avaliar a natureza dos acontecimentos que presenciam.

Não há razão para duvidar da palavra dos policiais que prestam serviço público de enorme utilidade à sociedade, mormente porque seus depoimentos encontram escoro nas demais provas idôneas produzidas nos autos.

O Estado credencia os policiais para o exercício da repressão criminal outorgando-lhes certa parcela do poder estatal e o Judiciário empresta essa mesma credibilidade quando chamados a prestar contas do exercício de sua função.

Assim, toma-se por verdadeiras as palavras dos policiais que nenhum motivo tinham para inventar fatos inocorridos.

A alegação de que os policiais forjaram as drogas também não conta com qualquer mínimo respaldo.

Com efeito, não havia motivo algum para que os policiais o incriminassem com drogas. Essa tese levantada pressuporia que os policiais seriam corruptos e que incriminariam as pessoas a seu alvedrio, o que se mostra absolutamente inveossímil.

Não se vê, nesse ponto, qualquer motivo para que os policiais agissem dessa forma. A polícia está a serviço da justiça e, com exceção de alguns poucos casos – que sempre são repreendidos de forma severa – a quase que totalidade dos policiais é honesta e não se presta a delitos. A alegação busca somente livrar o réu de sua certa responsabilidade e se tornou verdadeira cantilena.

O que se denota, mais uma vez, é uma tentativa desesperada de atribuir aos policiais, que atuam ao lado da lei, a responsabilidade que é do réu, desviado em sua conduta, valendo-se de meios ilícitos e ilegais para obter dinheiro fácil.

Por outro lado, não resultou evidenciada a alegação de que os policiais atiraram no réu e no garupa, revelando-se a versão inteiramente frágil.

A afirmativa de que fugiram da polícia porque ouviram tiros e pensou que seriam mortos não resultou evidenciada e não passa de uma tentativa inútil de afastar sua responsabilidade.

Verifica-se que o réu foi devidamente avisado da ordem de parada emanada dos policiais, que se valeram de sinais sonoros e luminosos, e foram atrás deles até um outro bairro, onde foram pegos. Nesse particular, não havia razão para continuarem fugindo depois de terem caído com a moto, e mesmo assim o fizeram, tentando o réu dispensar a droga.

Nesse particular, a par de estarem os policiais fardados, estavam com veículo policial devidamente caracterizado e se valeram de sinais luminosos e sonoros, e mesmo assim o réu empreendeu fuga com a motocicleta e mesmo após se acidentarem, continuaram correndo na tentativa de fugir da abordagem policial.

Sequer a posse da moto foi justificada, alegando o réu, sem qualquer evidência, de que comprou de um amigo há pouco tempo, sem documentação ou mesmo habilitação.

Assim, tinha o réu pelo menos três motivos para não obedecer a ordem de parada – como efetivamente o fez: levava drogas consigo, não era habilitado e nem tinha a documentação da moto.

Nada obstante, impende ser registrado que as testemunhas arroladas pela defesa ostentam vínculo com o réu, de forma que o teor do depoimento delas deve ser recebido com natural reserva. Uma das testemunhas é irmã do réu e não viu a sua abordagem e detenção; a outra era o rapaz que acompanhava o réu e que igualmente tentou se evadir da abordagem policial, mesmo sem ter com ele nada de ilícito, e por óbvio não viu a detenção do réu, e a última se declarou vizinho do réu, mas estar no local da abordagem, tendo afirmado que ao ouvir tiros todos correram e só viu o réu já abordado e sendo colocado na viatura, de forma que sua assertiva de que o réu não dispensou a droga deve ser creditada à tentativa de favorecer o réu,

pois não é verossímil.

Impõe-se anotar a menoridade relativa do réu, uma vez que na época dos fatos contava com menos de 21 anos de idade.

Há de se reconhecer, ainda, que o delito em questão se amolda no artigo 33, §4.º, da Lei 11.343/06. Isso porque o réu é primário, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas nem integra associação criminosa, o que demanda a redução pelo máximo de 2/3.

Vê-se, nesse contexto, que o réu era, por ocasião dos fatos, imputável e tinha plena consciência do ilícito perpetrado, não havendo excludente de ilicitude ou de culpabilidade que viesse em seu benefício.

A prova nos autos produzida, atenta ao contraditório e à ampla defesa, é segura e não deixa dúvida de que praticou a conduta descrita na denúncia, devendo responder pelo crime em questão.

Afirmada a responsabilidade, passo à dosimetria da pena, atendendo-se à disposição do artigo 68, do Código Penal, ao critério trifásico proposto por Nélson Hungria e ao princípio da individualização da pena.

Na primeira fase impende observar a regra do artigo 42, da Lei 11.343/2006, pelo qual preponderam sobre o artigo 59 a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social da agente.

A qualidade da droga (cocaína) e quantidade não pesa em desfavor do réu.

No que se refere à personalidade do agente - que no entender de Guilherme Nucci é aquela que está vinculada às qualidades morais, às distorções de caráter, à índole do sujeito, que são extraídos de sua forma habitual de ser, agir e reagir (in Individualização da pena, RT, 2005, p. 207) - se mostra negativa.

Isso porque resultou claro que o réu mentiu em Juízo quando alterou a versão dos fatos ocorridos, trazendo exposição falsa acerca de como se passaram os fatos, visando a uma injusta absolvição, conduta que no caso concreto se revelou ainda mais censurável pois atribuiu aos policiais a prática de grave crime. Essa atitude demonstra a distorção de caráter e a ausência de senso moral por parte do réu, que se vale da mentira com o propósito de impor tumulto à instrução processual e, maliciosamente, induzir em erro o julgador, com afronta à dignidade da justiça.

Sobre a questão, oportuno ressaltar que ainda que seja o interrogatório um meio de defesa e de prova, evidente que o réu deva respeitar as limitações impostas pelas regras do processo, especialmente aquelas decorrentes da lealdade, da ética, da boa-fé, não se podendo esquecer que o processo é um instrumento para a realização da Justiça, dotado de uma série de formalidades que, em ultima ratio, são verdadeiras garantias para o réu, como também para a sociedade.

Ora, é forçoso reconhecer que o réu ao mentir deliberadamente extrapola os limites da autodefesa - que não é absoluta - demonstrando torpeza e deslealdade processual, expondo a risco a Justiça que pode, em razão de seu proceder, proferir decisão equivocada e, assim, injusta.

Afigura-se evidente que não se pode tolerar que o réu se valha de engodos, ardis e mentiras visando a escapar de uma justa condenação. O acusado que assim age, frauda a produção de provas e torna o processo uma chicana pessoal e egoísta, revelando sua personalidade dissimulada, amoral, o que justifica a elevação da pena.

Acerca do tema, pertinente o registro da lição de Andrey Borges de Mendonça (Prisão

e outras Medidas Cautelares Pessoais, 2011, Método, p. 194): "Parece-nos, assim, que se o juiz constatar que o réu mentiu, poderá considerar tal circunstância no momento da pena. Não é que se esteja estimulando a confessar - até porque para isto já há uma circunstância atenuante genérica -, mas apenas negando que ao juiz e ao Poder Judiciário possa se admitir que o réu venha em juízo e, perante um agente do Estado, possa mentir livremente, como se isto fosse algo normal e aceitável, como se entende atualmente".

O entendimento acima explicitado, ainda que minoritário na jurisprudência, tem sido prestigiado em várias decisões judiciais, cabendo o registro, por todas, de parte do judicioso voto da lavra do Desembargador José Raul Gavião de Almeida, na Apelação 00771651-20.2015, da 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgada em 30 de novembro de 2017 :

"...Se o réu optar por falar, no interrogatório, deverá medir suas palavras, porque elas poderão ser utilizadas também em seu desfavor. É o que ocorre na hipótese do acusado apresentar versão contrária ao convincente conjunto probatório. Identificado que faltou com a verdade, esse comportamento e o teor da inexatidão podem ser considerados pelo julgador, pois não existe direito à mentira, como não há a correspondente obrigação de ignorar a verdade".

Ainda sobre o tema, se revela oportuno registrar parte do artigo " A mentira do réu como elemento relevante na dosagem da pena", da lavra do Promotor de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Cleber Pereira Defina, que de forma judiciosa analisou o tema:

"...assim como a confissão dos fatos denota aspecto louvável da personalidade do agente, pois atua com boa-fé e consciência social, o inverso também é verdadeiro: a mentira do agente sinaliza aspecto censurável de sua personalidade, pois atua com má-fé e franca ausência de consciência social, constituindo-se, portanto, em dado sensível quando da individualização da pena. O indivíduo que mente à autoridade só pretende beneficiar-se com a própria torpeza, conduz ao indesejável erro judiciário, prejudica o direito das vítimas e mina a justiça. Este cenário ratifica a deformação dos valores carregados pelo acusado pinoquista, repercutindo em necessidade ainda maior de reconstituição da tábua de valores socialmente almejada em relação ao acusado enganador. Ora, se é justo que a postura de lealdade do imputado deve surtir efeito no sentido de diminuir sua reprimenda, porque atrelada a condições favoráveis de sua personalidade, segue-se clarividente que há mesma justiça em extrair efeito no sentido de agravar a reprimenda do réu que ostenta péssima personalidade caracterizada pela insolência de mentir perante as autoridades que colheram sua versão dos fatos, especialmente quando a este acusado lhe foi garantido o direito ao silêncio. Aliás, onde o silêncio for útil, não se justifica a mentira. O mesmo Estado que garante ao processado o direito ao silêncio, a possibilidade de não se autoincriminar, que pode criar recompensas para este falar, como é o caso da atenuante da confissão e do acordo da delação premiada, também deve poder intensificar a reprimenda daquele que ousa falar com o exclusivo propósito de enganar e promover injustiça. O embuste, tanto quanto a lealdade, é vetor a moldar a pena justa, pois ambos dizem respeito à personalidade refletida do agente"http://www.esmp.sp.gov.br/revista_esmp/index.php/RJESMPSP/article/view/148/68).

Em suma, todo acusado tem o sagrado e inafastável direito ao silêncio, que decorre da garantia democrática de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo (nemo tenetur se detegere ou privilege against self incrimination); contudo, tal direito não pode admitir a interpretação que alguns lhe emprestam de tornar aceitável, ou pior, irrelevante, a conduta comissiva de mentir, que é vil, antiética e contrária aos valores mais mezinhas da sociedade, ao revés, deve o julgador, por ocasião da individualização da pena, caso constatado que o réu mentiu

ao ser interrogado em juízo, fixar a pena-base em patamar superior ao mínimo, amparado na personalidade negativa do acusado, pois evidente a ausência de senso moral, denotando índole desviada e personalidade distorcida, daquele que podendo se calar opta deliberadamente por mentir em juízo.

Não se pode olvidar, ainda, que o réu, desde a promulgação da Lei 11.719/2008, é interrogado após a colheita de todas as provas, inclusive depoimento das testemunhas, de forma que tem plena consciência das provas produzidas e da sua repercussão, mormente em razão da defesa técnica que o assiste, razão pela qual a sua opção pela mentira se mostra ainda mais censurável, cínica e abjeta, pois abre mão do direito ao silêncio, e até mesmo da atenuante da pena da confissão, para tentar induzir em erro o juízo e assim ferir a dignidade da justiça.

A propósito, impende registrar, por relevante, que caso o julgador não aumente a pena do acusado mendaz, "estará incentivando o réu a sempre mentir, afinal, se sua mentira não lhe causa qualquer prejuízo, podendo, inclusive, livrá-lo de uma condenação justa, por que confessar um crime ou mesmo ficar em silêncio? Não punir o acusado mentiroso, aliás, viola o princípio da individualização da pena, pois equipara equivocadamente a situação do réu que fica em silêncio em seu interrogatório, com a do que mente descaradamente, em verdadeira afronta à dignidade da Justiça, pois tem o único propósito de induzir esta em erro, minando, assim, sua credibilidade perante a sociedade" ("A mentira do réu e a Dosimetria da Pena", artigo de autoria do Promotor de Justiça, Dr. André Wagner Melgaço Reis, publicado na rede mundial de computadores, no endereço <http://www.cartaforense.com.br/autor/andre-wagner-melgaco-reis/958>).

Nesse passo, cabe trazer recentíssima decisão proferida pelo voto do i. Desembargador Tetsuzo Namba:

"...demaís disso, se eles tinham a opção de confessar ou ficar em silêncio, no momento que se pronunciavam, suas palavras devem ser ponderadas, se mentem, como no caso dos autos, isso não pode ficar sem avaliação valorativa negativa, sob pena de deixar de lado quem, muitas vezes, colabora com a Justiça e diz a verdade, seria o patrocínio indevido da "não verdade", isso mostra o caráter de alguém, flagrado no cometimento de infração penal, não se arrepende, ao contrário, faz de tudo para se livrar das imputações... (TJSP - Apelação Criminal 0001611-29.2018.8.26.0625, 8.^a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 28.11.2019).

Cabe anotar que o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, em julgamento recente, por votação unânime, decidiu no mesmo sentido da tese que ora se adota, trazendo excertos de decisão proferida por este juízo como razão de decidir, como se infere dos autos da Apelação nº 0000129-67.2018.8.26.0618, de relatoria do ilustre Desembargador Roberto Porto:

"Ademais, como bem destacou o Ministério Público a fl. 277 o fato de o réu ter mentido em Juízo, trazendo aos autos fatos absolutamente inverídicos, revela sua personalidade desvirtuada, devendo ser considerado no momento da exasperação da reprimenda. Aliás o Douto Magistrado bem fundamentou a exasperação da pena-base..."

No mesmo sentido já decidiu a Colenda 14^a Câmara de Direito Criminal, por votação unânime nos autos da apelação nº 0000640-36.2016.8.26.0618, de relatoria do ilustre Desembargador Walter da Silva:

"(...) Em relação ao delito previsto no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03: Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, a pena base foi bem fixada acima do mínimo legal, fundamentando o douto Magistrado na personalidade negativa do apelante, pois demonstrou perante o Juiz desonestidade e insinceridade, o que revelou a distorção de caráter, e assim a reprimenda foi tornada definitiva na ausência de outras causas modificadoras."

Ainda sobre a mentira do réu como circunstância desfavorável, com enfoque na personalidade desviada, em voto proferido pela 6.^a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, pela voz do ilustre relator Zorzi Rocha, assentou:

“Dessa forma, se o réu mentir em seu interrogatório, negando a prática do crime por ele cometido, ou explicando o crime ao apresentar uma versão fantasiosa do fato, tudo a fim de se obter uma injusta absolvição, justificado está o aumento de sua pena-base com fundamento na personalidade negativa. Afinal, a insinceridade e a desonestidade demonstradas perante o Juiz – como explanado no item 2 suso exposto – revelam distorção de caráter e ausência de sendo moral por parte do Réu, que se utilizou da mentira – subterfúgio repugnado pela ética e pelo dever de lealdade – com nítido propósito de tumultuar a instrução processual e induzir em erro o julgador, afrontando, assim, a dignidade da Justiça” (TJSP – Apelação Criminal 0001317-32.2017.8.26.0618, j. 3.10.2019).

Não outra a conclusão a que chegou o ilustre Des. Ricardo Sale Júnior, chamando atenção para a correção do decisum que elevou a pena-base pelo fato de haver o réu mentido ao ser interrogado em juízo “fato que evidencia uma personalidade voltada para o crime” (TJSP – Apelação Criminal 0002205-19.2013.8.26.0625, 15.^a Câmara de Direito Criminal, j. em 8.8.2019).

No mesmo sentido o voto da lavra do ilustre Des. Tetsuo Namba, ao aduzir correta a sentença que reconheceu a mentira do réu como personalidade deturpada, justificando-se a elevação da pena na primeira fase da dosimetria. (TJSP – Apelação Criminal 0001091-27.2017.8.26.0618, 8.^a Câmara de Direito Criminal, j. em 5.12.2019).

Também em processo que teve trâmite por esta 3.^a Vara, em sede de apelação (Apelação Criminal nº 0000037-05.2017.8.26.0625), a i. Desembargadora Ivana David, assentiu com a tese ora perfilada, nos termos seguintes, fazendo alusão, em parte, à decisão proferida nos autos do Processo Criminal nº 0003339-30.2014.8.26.0372, 1.^a Vara Judicial de Hortolândia - Juiz de Direito, Luis Mário Mori Domingues j. 21.01.2015.

“E escorreita a majoração praticada, uma vez que ao mentir em juízo, a acusada foi muito além do seu direito ao silêncio, mentindo para a Justiça, tentando se esquivar das consequências dos seus atos, porquanto, “nosso ordenamento jurídico, amparado por tratados internacionais e na linha de todos os demais sistemas penais do mundo garantem ao acusado o direito ao silêncio. Significa dizer que o réu, silenciando-se, não pode ser acusado com base nesse fundamento, isto é, ausente provas contra o réu, ele não pode ser condenado porque ficou em silêncio. Em momento algum o direito ao silêncio confunde-se com direito a mentira. O silêncio é uma conduta passiva, fundada no direito de não produção de prova contra si. A mentira é conduta ativa, é a produção de prova falsa em juízo”, demonstrando, com isso, além da má índole, que o crime não constituiu um episódio acidental em sua vida. (Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 10.12.2019).

Em outro processo que teve trâmite por esta Vara (1501572-71.2021), bem concluiu o Ilustre Desembargador Zorzi Rocha:

“A pena-base foi fixada em 1/6 (um sexto) acima do patamar mínimo, com fundamento no artigo 59 do Código Penal, destacada a rubrica da personalidade desregrada do Réu o qual modificou a realidade dos fatos com o nítido intuito de minimizar os efeitos de sua conduta, dificultar a análise da prova e criar a ideia de irregularidade da conduta policial. Não se trata de mera mentira narrada em Juízo, mas da criação de realidade diversa (disse que era tatuador e tinha um estúdio de tatuagem), com a produção de prova testemunhal nesse sentido (a testemunha João

Pedro disse em Juízo que foi tatuado pelo Réu, embora nunca tivesse visto seu estúdio/oficina). Destaque-se que o próprio Réu confirmou informalmente que produzia armas artesanais, fornecendo detalhes de como eram feitas a produção e a usinagem, sendo essa narrativa judicial conduta que realmente extrapolou os limites da autodefesa, podendo ser utilizada de forma regular e como aqui ocorreu para exasperação da pena-base." (Apelação Criminal, j. em 26.5.2022).

No que respeita à culpabilidade, o que se vê é natural à espécie.

O réu é primário.

Acerca da conduta social do réu não há elementos para que se proceda à sua valoração.

Quanto aos motivos do crime e as circunstâncias, nada há de relevante.

O sujeito passivo do tráfico de drogas é a coletividade, titular do bem jurídico a saúde pública, não havendo, assim, falar-se em comportamento da vítima.

Diante da personalidade negativa, elevo a pena mínima em 1/6 e fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, vislumbro a circunstância atenuantes da menoridade relativa, que, contudo, não pode levar a pena abaixo do mínimo legal em razão do disposto na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça. Não há, outrossim, circunstâncias agravantes, tornada a pena a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase da reprimenda, observo a causa de diminuição relativa ao artigo 33, §4.º, da Lei de Drogas, que importa diminuir a pena em 2/3, alçando-a ao patamar de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. Não há causa de aumento, razão pela qual fixo a pena definitivamente em 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 166 dias-multa.

Quanto ao regime inicial, de se lembrar que o tráfico privilegiado não ostenta natureza hedionda (Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 118. 533/MS), de forma que sendo a condenação inferior a 4 anos, somada à pequena quantidade de entorpecente, entende-se que, nesse caso, o regime imposto deve ser o aberto.

Nos termos do artigo 49, §1.º, do Código Penal, o valor do dia multa será de 1/30 avos do salário mínimo praticado à época do delito, pois ausentes elementos para aferição da capacidade financeira do réu, devendo ser atualizado pelos índices de correção monetária da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde aquela data até o efetivo pagamento.

Também, excepcionalmente, entendo possível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Isso porque a pena é inferior a 4 anos, o crime não foi cometido com violência, o réu não é reincidente, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, bem como os motivos e as circunstâncias indicam que essa substituição será suficiente.

Tendo em conta que a pena é maior que um ano, nos termos do artigo 44, §2.º, substitui-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direito consistentes na prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Em razão da substituição acima, incabível a suspensão condicional da pena, em razão do disposto no artigo 77, do Código Penal.

Deixo de fixar indenização mínima prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal pois inexistente pedido nos autos, fato que inviabiliza o

contraditório e a ampla defesa, bem como se afasta do princípio da congruência.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Anoto que no decorrer do processo esteve ele em liberdade, não se vislumbrando necessidade de alteração desse estado, prestigiando assim a presunção da inocência, pois ausentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar.

Como afirma Ricardo Schmitt, "como regra geral, temos que se o sentenciado se encontra solto, em liberdade plena no momento da sentença, tendo permanecido nesta situação durante a instrução processual, em princípio possui o direito de recorrer em liberdade, salvo se existir algum motivo ponderoso à aplicação de medida cautelar diversa da prisão, ou , em último caso, de decretação de sua custódia preventiva" (Sentença Penal Condenatória, 8.^a ed., Editora JusPodivm, Bahia, 2014, p. 443)

Não há dados suficientes para realização da detração da pena, razão pela qual deixa-se de cumprir o disposto no artigo 387, §2, do Código de Processo Penal, cabendo ao juízo da execução, que detém as informações necessárias, analisar oportunamente eventual direito do réu por conta do período que ele permaneceu preso cautelarmente, consoante determina o artigo 66, inciso III, alíneas "b" e "c". Nesse sentido: (HC 169.072/SP, relator Ministro Og Fernandes - 6^a Turma do Superior Tribunal de Justiça, julgado em 10.6.2010).

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, de acordo com o artigo 804, do Código de Processo Penal, indeferindo-se a gratuidade da justiça. Isso porque não há qualquer documento idôneo a comprovar a afirmada hipossuficiência.

Posto isso, acolho o pedido formulado na denúncia para o fim de condenar o réu Luiz Vinicius de Jesus à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 166 dias-multa, como incurso no artigo 33, parágrafo quarto, da Lei nº 11.343/2006, com início de cumprimento no regime aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direito consistentes na prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, condenando-o, outrossim, ao pagamento das custas no importe de 100 UFESPs, nos termos do artigo 4.º, § 9.º, alínea "a", da Lei estadual 11.608/03.

Após o trânsito em julgado deverá a Serventia levar a efeito as seguintes providências:

- a) intimar o réu para proceder ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686, do Código de Processo Penal, assim como ao pagamento da taxa judiciária;
- b) oficiar ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;
- c) oficiar ao IIRGD comunicando a condenação do réu;
- d) expedir guia de execução penal.

R.P.I.

Taubaté, 11 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA